

1500861-88.2022.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavio Roberto de Carvalho

Comarca: São Roque

Foro: Foro de São Roque

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... trazer consigo para fins de tráfico, sem autorização legal ou regulamentar, a droga proibida, basta para integrar a figura criminosa do tráfico ilícito. Vender, em tema de entorpecente, é uma das condutas típicas, e não "conditio sine qua non" de delito de tráfico ilícito. Nesse sentido: "Apelação - Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Roque

Foro de São Roque

1ª Vara Criminal

Av. John Fitzgerald Kennedy, Centro - CEP 18130-510, Fone: 11-2550-5296, São Roque-SP - E-mail: saoroquecr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500861-88.2022.8.26.0567

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 2112987/2022 - Delegacia de Polícia de Araçatiguama

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHAEL AURELIO DA SILVA DOS SANTOS

Aos 23 de novembro de 2022, às 15:30h, em ambiente virtual no programa Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Flavio Roberto de Carvalho, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceram o DD. Promotor de Justiça Dr. Washington Luiz Rodrigues Alves, o réu MICHAEL AURELIO DA SILVA DOS SANTOS, acompanhado de seu defensor Dr. Paulo Rogério Compian Carvalho OAB 217672/SP, a quem foi garantido a entrevista pessoal com o réu, em ambiente virtual, antes do início da audiência; e as testemunhas RAPHAEL SZABO, PAULO HENRIQUE DE CAMARGO TAVARES e SEBASTIANA MARGARIDA DA SILVA. Iniciados os trabalhos, pelas partes foi acordado que no termo somente constara a assinatura digital do magistrado já que o processo é digital, e novamente aceito pelas partes que a audiência seja feita nesta modalidade virtual pelo Microsoft Teams. Pelo MM. Juiz foram colhidos os depoimentos das testemunhas Raphael, Paulo Henrique e Sebastiana Margarida e realizado o interrogatório do réu Michael Aurélio. Pelo MM. Juiz foi declarada encerrada a instrução passando aos debates. Iniciados os debates o Ministério Público se manifestou de forma oral (constante na gravação). Em seguida o defensor do réu se manifestou também de forma oral (constante na gravação). Encerrados os debates pelo MM. Juiz foi proferida a Sentença: Vistos. MICHAEL AURÉLIO DA SILVA DOS SANTOS qualificado nos autos foi denunciado pelo Ministério Público, pela prática do crime tipificado no artigo 33, "caput" da lei 11343/06 porque nas

circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, tinha em depósito para fins de trafico, 231 frascos de lança perfume, 666 porções de cocaína, 132 de maconha, 169 de ecstasy, 571 de cocaína, drogas que determinam dependência física e psíquica, sendo certo que agiam sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Acompanhou a denúncia o inquérito policial (fls. 01/73) e documentos, onde se destaca: auto de prisão em flagrante (fls. 01/04, 07/08, 11/25), auto de exibição e apreensão (fls. 05/06), boletim de ocorrência (fls. 09/11), fotografia da apreensão (fls.35), auto de constatação preliminar (fls. 36/37), relatório de investigação (fls. 58/62), exame químico toxicológico (fls. 69/73). A denúncia foi recebida em 01 de agosto de 2022 (fls. 80/81), o réu foi citado e ofertou Defesa (fls. 147/149), prosseguindo a instrução com as oitivas de testemunhas e colheita do interrogatório. Em debates finais, o Ministério Público insistiu na condenação com fixação da pena acima do mínimo diante da quantidade de drogas apreendida com o acusado, não se opondo a aplicação do redutor. A Defesa insistiu em preliminar na nulidade da prova já que não existiu autorização para ingresso na residência e no mérito a aplicação da pena mínima, redutor e reconhecimento da confissão. É o relatório. DECIDO. Em preliminar a Defesa sustentou que a prova não seria lícita, pois existiu a invasão no domicílio, sendo que a matéria confunde-se com o mérito e será analisada no momento oportuno. No mérito a materialidade está comprovada a saciedade pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/04, 07/08, 11/25), auto de exibição e apreensão (fls. 05/06), boletim de ocorrência (fls. 09/11), fotografia da apreensão (fls. 35), auto de constatação preliminar (fls. 36/37), relatório de investigação (fls. 58/62), exame químico toxicológico (fls. 69/73, 181/185), laudo celular (fls. 186/193) corroborado pela prova oral coligida. Quanto à autoria, o acusado disse que guardou as drogas, pois estava devendo para Negueba, e era de um dia para o outro. Recebeu as drogas em uma sacola, e entregou para a polícia da mesma forma. A genitora limpa a casa, mas a droga ficou embaixo do sofá. O portão da casa é amarelo. Viu o rapaz descendo e ficou na sala, e depois ele estava na frente do seu portão. O portão do terreno estava aberto e os policiais estavam no quintal e indagaram a respeito de drogas, e disse que realmente tinha as drogas no local e entregou para os policiais. Disse ser usuário de drogas. A confissão do réu guarda estreita correspondência com a prova produzida. Raphael Szabo disse que estavam investigando o trafico no Município, e em um dos bairros, Jardim Brasil, existia grande movimentação, e identificaram indivíduos e residências onde guardavam drogas, sendo que a biqueira ficava no campo. Fizeram a campana na residência que era do réu, e não viram movimentação específica, pois ninguém atendeu a porta, ate que avistaram uma senhora na frente do local, e resolveram conversar com ela, e se identificou como a mãe do réu, e comentaram e ela abriu o corredor e levou ate a porta da casa do réu, onde ele estava, e conversaram a respeito, e de inicio percebeu que não era um rapaz assíduo no crime, admitindo que guardava drogas para terceiros pois estava devendo para um terceiro, e que abateria a divida. Com este relato ele entregou a sacola de drogas em grande quantidade, e foi conduzido ate a delegacia. A investigação prosseguiu, pois o réu indicou o proprietário, que era pessoa conhecida e que ficou preso. Ele identificou o Negueba, que era conhecido no trafico na cidade. Estava ha três semanas guardando drogas. Não conhecia o réu. Já estavam investigando o Negueba e com diligencias, descobriram que ele guardava as drogas no local e fizeram a campana para o flagrante e nessa oportunidade viram a mãe do réu saindo da casa, e isso foi estranho, e resolveram averiguar, e com isso acabou em contato com o réu e acabaram abordando o acusado. Se a senhora não tivesse franqueado a entrada não seria possível acessar o imóvel. Paulo reiterou o depoimento de Raphael, acrescentando que o réu disse que fez uma divida com Negueba e não conseguiu pagar e por isso guardou a droga para pagar a divida. durante a campana mais de uma pessoa foi ate a casa e não foi atendida. Sebastiana disse ser ame do réu, e no terreno tem varias casas separadas, com um portão social, e o réu trabalhava no posto de gasolina, e desconhecia se ele devia algo para alguém. Conhece Negueba e não viu ele com o filho. Desconhecia que o filho armazenava drogas, e um rapaz bateu e queria falar com o filho, e que ele teria se envolvido em uma briga, e indagou a respeito do telefone, e quando entregou, ele se

identificou. O rapaz saiu e com isso ligou para Michael, pois pensou que ele estava trabalhando, e disse que não se envolveu em briga, e disse que estava na casa. Passou na casa do réu, e disse que não se envolveu em briga. Quando voltou a residência, e novamente bateram no portão, e perguntaram se ele estava na casa e eles desceram e não sabiam onde o filho morava e indicou o local onde ele morava. Saiu quando eles entraram, e quando voltou tinha 04 policiais, e eles disseram que o filho guardava drogas. Trouxeram o filho para o carro, e eles mostraram a sacola. O filho negou que guardava drogas. Não sabe como as drogas estavam no local, e sempre acompanhava as pessoas que frequentavam o local, e limpava a casa e nunca viu nada. Não conhecia os policiais. Quem chama no portão social, tudo mundo escuta, e o réu chegou do serviço, pois ele trabalhou de manhã. Limpou a casa na sexta-feira e depois não entrou mais no local. Vale mencionar que nenhuma restrição merecem os depoimentos dos policiais, mormente quando suas declarações vêm corroboradas por outros elementos de prova e também quando não levantada qualquer suspeita fundada e demonstrada. Nesse sentido: "não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria um contrassenso credenciar o Estado alguém a atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado-Juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito." (TACRIM-SP JUTACRIM 30/221). Com efeito, conforme amplamente decidido, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54), entre outros arestos (RT 530/372, 411/266, 445/382 e RJTJESP-LEX 136/476). Ademais, seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhe negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682). Por isso, eventuais pequenas contradições entre os depoimentos prestados em Juízo, se comparados entre si e com os da fase administrativa, são naturais e reforçam a ausência de prévia combinação entre as pessoas ouvidas, ou qualquer sanha obstinada em falsa incriminação. Observa-se ainda que, "pequenas dissonâncias na prova oral não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais discrepâncias, em pontos secundários, que são fruto das imperfeições do psiquismo humano" (JUTACRIM 95/262). "O depoimento do policial é tão válido como outro desde que insuspeito e capaz de infundir, pelo seu conteúdo, incredibilidade. Por outro lado, nos termos do art. 202 do CPP, se toda pessoa pode ser testemunha, sem qualquer dúvida que os agentes podem testemunhar sobre o que viram e sentiram no cumprimento da missão. Se por/acaso outras pessoas havia no local da diligência, cumpre à defesa arrolá-las como testemunhas. Também pequenas divergências que não atingem a substância do fato não são suficientes para ilidir aprova" (RT574/401). "PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Servidores que não estão impedidos de depor - Testemunhas, ademais, que não foram sequer contraditados em Juízo - Recurso provido. Os policiais militares, como qualquer outra pessoa, não estão impedidos de depor e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerando suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial, (relator Ângelo Galluci - Apelação Criminal nº 153.694-3-São Paulo-26.09.94)". "DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. - O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em Juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova". (STJ, 5.a Turma, HC 110869/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, v.u., j. 19.11.2.009; pub. DJe de 14.12.2.009). Não trouxe o acusado qualquer prova ou elemento a contrariar a idoneidade do depoimento policial. Pelo contrário, os policiais sequer conheciam o réu, e não teriam motivos para incriminá-lo injustamente, não sendo crível que policiais transitem com drogas para prejudicar terceiros desconhecidos. É fato que os policiais já estavam investigando o tráfico, e obtiveram a informação do local de armazenagem, e fizeram a campana, sendo que chamou a atenção a existência de uma mulher o que não é comum em casas

bomba, e foram falar com a mesma, que apontou o local de residência do filho e de fato, os policiais sequer entraram na casa, tanto que foram atendidos pelo réu, que entregou espontaneamente as drogas para os policiais, sendo que admitiu que eles não entraram na residência, e ficaram no quintal. Ainda o próprio réu auxiliou no tocante a identificação do proprietário da droga, e em audiência manteve que existiu a autorização para os policiais que sequer conhecia. Não se olvide que o próprio réu disse que estava devendo valor para Negueba e que por não conseguir pagar teve que guardar a droga como forma de quitação, e que seria de um dia para o outro. Realmente não era caso de mandado de busca e apreensão, pois como pontuado pelos policiais estavam iniciando a investigação, levantando locais e dados e que se não fosse pelo contato com a genitora do réu talvez nem mesmo a abordagem tivesse acontecido. Não se olvide que a própria genitora passou o telefone do filho para os policiais, e quando eles retornaram, a mesma não se opôs a abertura do portão de acesso ao terreno das demais casas. Mas não é só, o próprio réu disse que os policiais não entraram na sua casa, e ficaram no portão tanto que em conversa de imediato entregou as drogas. Ainda, a fundada suspeita estava presente já que existia a investigação, e local onde existiam as drogas, sendo que não impeditivo da ação policial eventual contato com moradores para esclarecimentos como aconteceu no presente caso. Realmente até pelo depoimento do próprio acusado não existiu qualquer invasão a residência. Por fim, não se olvide que o réu estava em situação de flagrante delito, o que justificaria a atuação policial. Nesse sentido: "TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, POSSE DE PETRECHOS DESTINADOS AO PREPARO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO RECURSO DEFENSIVO: PRELIMINAR NULIDADE DO PROCESSO PROVA ILÍCITA INOCORRÊNCIA PRISÃO E BUSCA DOMICILIAR DENTRO DE RESIDÊNCIA AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO IRRELEVÂNCIA CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAVAM A OCORRÊNCIA DE CRIME DE CARÁTER PERMANENTE PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO FLAGRANTE CARACTERIZADO PRELIMINAR REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, POSSE DE PETRECHOS DESTINADOS AO PREPARO DE DROGAS RECURSO DEFENSIVO: INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ABSOLVIÇÃO INADMISSIBILIDADE PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS CONDENAÇÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. POSSE DE PETRECHOS E MATERIAIS DESTINADOS À PREPARAÇÃO E FABRICAÇÃO DE DROGAS CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS: SITUAÇÃO EXCEPCIONAL "IN CONCRETO" TIPICIDADE CONDENAÇÃO RECURSO NÃO PROVIDO (Apelação Criminal com Revisão nº 0002674-18.2014.8.26.0597 3ª Câmara Criminal TJSP relator Desembargador Dr Jayme Walmer de Freitas, 21/11/2022). Ainda no mesmo Acórdão, em seu corpo: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. ELEMENTOS CONCRETOS DA AUTORIA E LOCAL DE DEPÓSITO DA DROGA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II O estado flagrancial do delito de tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inc. XI do art. 5º da Constituição Federal, sendo permitida a entrada em domicílio independentemente do horário ou da existência de mandado. Esse é entendimento dominante acerca do tema nesta Corte, no sentido de que "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no Resp n. 1.637.287/SP Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, Dje de 10/05/2017). (...) Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HABEAS CORPUS Nº 747053 SP, Rel. Min. Jesuino Rissato, Quinta Turma, j. 02/08/2022). "I - É cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. II - O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência do recorrente, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais

hipóteses." (STJ, AgRg no Habeas Corpus nº 656.042 SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 25/05/2021). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. COTEJO ANALÍTICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. FRAÇÃO ADEQUADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 4. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). "No caso, de acordo com o consignado pelas instâncias ordinárias, os policiais receberam denúncia anônima de que havia movimentação indicativa da existência de drogas no apartamento do réu, foram até o local com o síndico e, quando o acusado abriu a porta para atender, visualizaram os entorpecentes em cima da mesa. Vale dizer, além das denúncias anônimas, os policiais tiveram certeza visual da situação de flagrância de crime permanente no interior da casa antes do ingresso. Assim, as circunstâncias acima descritas indicam que o ingresso foi precedido de fundadas razões objetivas e concretas da existência de drogas no local. Desconstituir as premissas fáticas assentadas pelas instâncias ordinárias implicaria a necessidade de reexaminar todo o conjunto fático-probatório, providência que esbarra na Súmula n. 7 deste Superior Tribunal. (...) 9. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no Recurso Especial nº 1.998.221 SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma. J. 14/06.2022). Portanto, a prova mostrou que os policiais estavam investigando local onde haviam drogas armazenadas, bem como, em contato com a genitora esta indicou a casa do réu, e no endereço deste, o acusado atendeu e explicada a situação de imediato entregou as drogas, sem a necessidade de vistoria da casa, estando em flagrante delito, ou seja, existiam as suspeitas, bem como a dinâmica da investigação, que culminou com a identificação do réu o qual de imediato contribuiu para a investigação, como relatou em seu interrogatório, o que afasta a tese da Defesa. Em suma, os depoimentos colhidos, à luz do contraditório e as demais provas acostadas aos autos, somadas a efetiva apreensão de droga, evidenciam a realidade do tráfico exercido pelo réu. Vale citar: "Adquirir, guardar, vender, ou trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, substância entorpecente, são condutas comuns aos delitos de tráfico ilícito e uso indevido, do que resulta, pelo princípio da exclusão, quando não se tratar de uso indevido, reconhecer o narcotráfico. Caracteriza o delito de tráfico ilícito de substância entorpecente trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, maconha e cloridrato de cocaína, em doses unitárias, de pequenos embrulhos, embalagem usual do varejo das drogas" (TJRJ - AC 1.185/93 - Rel. Enéas Machado Cotta - TDTJRJ 23/288). A lei pune o tráfico ilícito de entorpecente em qualquer de suas condutas, típicas e exclusivas. Em tema de entorpecente, a conduta de guardar, ter em depósito, trazer consigo para fins de tráfico, sem autorização legal ou regulamentar, a droga proibida, basta para integrar a figura criminosa do tráfico ilícito. Vender, em tema de entorpecente, é uma das condutas típicas, e não "conditio sine qua non" de delito de tráfico ilícito. Nesse sentido: "Apelação - Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria devidamente demonstradas nos autos, pela prova documental e oral - Conjunto probatório suficiente à condenação - Pleito visando a desclassificação para o delito de porte de drogas - Impossibilidade - A diversidade, a forma de acondicionamento da droga, sua quantidade, assim como as circunstâncias da apreensão, demonstram, à evidência, que o entorpecente se destinava ao tráfico - Pena e regime corretamente fixados - Sentença mantida - Apelo improvido. (Apelação nº 0005711-21.2009.8.26.0050, TJ/SP, 16 Câmara de Direito Criminal, negaram provimento, v.u, data julgamento 01/03/2011,

relator Des. Borges Pereira) "A inversão do ônus da prova, uma vez que o trabalho acusatório demonstrou suficientes indícios de autoria, além de prova cabal da materialidade do crime, incumbindo, pois, às defesas indicarem fatos que afastasse, inequivocamente, os seguros indicativos da participação das acusadas no crime. "Para a formação de um juízo de certeza razoável sobre o comércio de entorpecentes, não é necessária prova efetiva do tráfico. O conjunto de indícios e elementos que cercam o agente infrator podem fornecer o material de convencimento da traficância. Inexige-se, portanto, prova flagrancial do comércio ilícito, bastando, como já dito, elementos indiciários, como 'confissão extrajudicial, a quantidade e qualidade do material apreendido, a conduta e os antecedentes do agente, bem como as circunstâncias da prisão' (art. 37, LT), ser substância oriunda de área e rota de comércio ilícito etc. Erigir-se, como regra, a necessidade de prova direta da finalidade comercial da substância entorpecente em poder do acusado, para fazer incidir o art. 12, por um lado é inviabilizar o combate ao tráfico e ao mesmo tempo dar ensejo à disseminação do comércio ilícito. Além de sob o ponto de vista jurídico constituir-se numa teratologia." (RODRIGUES, João Gaspar. Tóxicos: Abordagem crítica da Lei nº 6.368/76. Campinas: Bookseller, 2001. p. 157).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO-DE ENTORPECENTES - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - RESPEITO AO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO REO - PRETENSÃO IMPROCEDENTE - DEPOIMENTO POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE - RECURSO IMPROVIDO. Não há falar em absolvição com base na negativa de autoria isolada nos autos, quando os demais elementos de prova, como depoimento prestado por policial dão suporte à condenação do réu. O testemunho prestado por policial é válido e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se traga aos autos, porquanto são revestidos de presunção de veracidade até que haja prova em contrário. (Apelação Criminal - Reclusão - N. 2010.002225-8 - Três Lagoas - Relator - Des. Claudionor Miguel A. Duarte - Julgamento: 8/3/2010) Apelação - Tráfico DE ENTORPECENTES - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA - Interceptação Telefônica PROVIMENTO PARCIAL. Mantém-se a condenação do acusado pelo tráfico de entorpecentes quando devidamente caracterizadas a autoria, a materialidade e tipicidade. [...]. O crime de tráfico de entorpecentes é de natureza múltipla, caracterizando-se quando o agente pratica um ou mais dos núcleos do tipo previsto no art.33 da Lei 11.343/06. (AC nº 1.0384.07.053086-8/001 - Rei. WALTER PINTO DA ROCHA - Data da Publicação: 04/04/2008). É certo que para a caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos carreados, como as circunstâncias da prisão, a quantidade do entorpecente, o local da infração, etc. Nesse sentido, sobre o valor probatório dos indícios, cita-se a lição de Julio Fabrinini Mirabete, constante no acórdão do ilustre Relator Borges Pereira(Apelação nº 0005711-21.2009.8.26.0050, TJ/SP, 16 Câmara de Direito Criminal, negaram provimento, v.u, data julgamento 01/03/2011), a saber:(...) tanto mais forte o indício quanto mais íntima sua relação com o fato, não havendo princípios inflexíveis sobre o valor da prova indiciária no processo (...) diante do sistema da livre convicção do juiz, encampado pelo Código, a prova indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, como se atesta na exposição de motivos, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a outra. Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado, (in Código Penal Interpretado - Ed. Atlas - SP -1999 - pág. 532). (citado no corpo do acórdão da apelação 0005711-21.2009.8.26.0050, TJ/SP, 16 Câmara de Direito Criminal, negaram provimento, v.u, data julgamento 01/03/2011, relator Dês. Borges Pereira) Desta forma a procedência da ação é de rigor. Passo a dosimetria da pena. Atento ao disposto no artigo 42 da Lei 11343/06 e art.59 do Código Penal, verifico que a quantidade de droga era significativa, e renderia lucro considerável, e com grande valor econômico o que mostra a desvalia da conduta, sendo que este fator, pode ser usado na fixação da pena base. Nesse sentido: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ART. 42 DA LEI 11.343/06. EXASPERAÇÃO DA

REPRIMENDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 1. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre na espécie, na fixação das penas, deve-se considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06. 2. Verificado que foi levada especialmente em consideração a natureza e a quantidade da substância encontrada - 693 g (seiscentos e noventa e três gramas) de cocaína -, não há que se falar em constrangimento ilegal quando a sanção básica foi fixada apenas seis meses acima do mínimo legalmente previsto, vez que apontados fundamentos concretos a justificar maior reprimenda. Ordem denegada" (STJ - HC nº 231882/SP rel. Min. Jorge Mussi j. 20/06/2012). "A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se deve basear. 2. Idônea a exasperação da pena-base com fundamento na natureza das substâncias traficadas, consoante preconiza o art. 42 da Lei 11.343/2006 c/c art. 59 do Código Penal. 3. A avaliação do quantum de atenuação da pena, à míngua de previsão legislativa dos parâmetros a serem considerados, sujeita-se ao livre convencimento motivado do julgador, observado o limite máximo de redução, as circunstâncias do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade" (STF - RHC 129951 / PR Rel. Min. Teori Zavascki Segunda Turma DJe 08/10/2015.). Assim, reconhecendo este fator, a apontar a culpabilidade acima da media, o que leva a fixação da pena em 1/5 acima do mínimo. Ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão que leva a pena ao mínimo legal. Não estão presentes causas de aumento de pena. Possível a aplicação do reduto, e em que pese a quantidade de drogas, é fato que o réu contribuiu para o deslinde da investigação, identificando o proprietário dos entorpecentes, ou seja, seu ato representou auxílio efetivo, e por este motivo, deve-se aplicar a redução máxima, totalizando a pena em 01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa. Fixo a míngua de outro elemento o dia-multa no mínimo legal. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o réu, por não ser permitido pela lei 11343/06, e por partilhar do entendimento da inviabilidade do acolhimento de tal benefício em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecente. Realmente o delito de trafico envolve o que há de pior no ser humano em relação ao seu semelhante, lucrando-se e aproveitando-se da fraqueza humana, destruindo dependentes e familiares. Na verdade a droga se constituiu no principal mote da violência, sustentando toda uma cadeia criminoso, com lucro fácil, não sendo possível, premiar o traficante que tanto mal causa a terceiros com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Saliento que não seria possível a aplicação da substituição tendo em vista a vedação do inciso III do artigo 44 do Código Penal, já que possui circunstância judicial negativa. . Incabível a suspensão condicional da pena, pelas mesmas razões. "RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. RECURSO PROVIDO. 1. Não tem direito à suspensão condicional da pena quem é condenado por crime de tráfico de drogas, positivado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, por expressa vedação do art. 44, caput, dessa lei. (...)" (STJ, REsp 1373032/DF, 6ª Turma, Min. Rogério Schietti Cruz, jg. 17/12/2015, DJe 11/03/2016) Levando-se em consideração a quantidade de drogas, e o alcance significativo de usuários, a indicar uma maior reprovabilidade da conduta, somado as circunstâncias judiciais negativas já reconhecidas, e pontuando-se o bem jurídico protegido, além da pena aplicada, fixo o regime inicial semi aberto. Considerando o tempo de prisão já faz jus a modificação do regime, de modo, que com esta detração, o regime será o aberto. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado constante na denúncia, para CONDENAR como incurso no artigo 33 § 4 da lei 11343/06,

o réu MICHAEL AURÉLIO DA SILVA DOS SANTOS a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses s reclusão em regime inicial aberto (já considerado o tempo de prisão como detração do semi aberto), além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa cujo valor unitário consiste em um trigésimo do salário mínimo mensal vigente no dia dos fatos (art. 49, § 1º, do mesmo Código), a partir do qual será atualizado, em conformidade com o art. 49, § 2º, primeira parte, do aludido

Estatuto Penal (cfr. SEBASTIÃO DA SILVA PINTO em RT 645/255-262; TACRIM em RT 682/335, 782/614, JUTACRIM 95/45; STJ em RE 41.438-5-SP, 5ª T., Rel. Min. ASSIS TOLEDO, em D.J.U. 17/10/94, pág. 27.906; STJ - Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 91.003-RS - 3ª S - Rel. Min. Gilson Dipp - J. 13.12.99 - DJU 21.02.2000; STJ, RE 22.497/8-SP, 5ª T., Rel. Min. José Dantas, DJU 13.10.1992, p. 17.700 etc). Custas pelo acusado nos termos da lei. Possível a concessão da liberdade mediante as seguintes cautelares: Comparecimento mensal em juízo, proibição de frequência a bares, danceterias e locais mal afamados, recolhimento domiciliar diário a partir das 19:00 com exceção de trabalho, estudo ou frequência a culto religioso. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Autorizo assegurada a contraprova e desde que não providenciado, a incineração da droga apreendida independente do trânsito em julgado. Ainda decreto o perdimento do celular. Oportunamente, após o trânsito providencie-se o necessário para o efetivo cumprimento da sanção imposta, comunicando o IIRGD e a Justiça Eleitoral e remetendo-se após ao arquivo com as cautelas de praxe. Sentença publicada em audiência. Pelo Ministério Público foi dito que desistia do prazo recursal. Pela Defesa e pelo réu foi dito que interpunham recurso. Pelo MM Juiz foi decidido: Homologo a desistência do recurso ministerial e recebo o recurso da Defesa saindo intimada para apresentar razões no prazo legal. Com a juntada manifeste-se o Ministério Público, e apos encaminha-se ao Tribunal de Justiça com nossas homenagens. Saem os presentes intimados. Nada mais. Eu, Guilherme Parra Magri, digitei.

O arquivo de vídeo e áudio com a gravação da presente audiência, encontra-se disponível às partes no link:

Parte 1:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/gmagri_tjsp_jus_br/EcysB-vBhkFDhHskw3wKcYwBfTwaNRIBwDD23ZlwU6eRZg?e=C6S9Il

Parte 2:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/gmagri_tjsp_jus_br/EaDLUIfLiz1LhIegCV3iMEoB89lPWVKqnk1kCHQolp-5zA?e=5W5PH2

MM. Juiz: assinado digitalmente